

1502421-92.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem. Nesse sentido temos: A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502421-92.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/001793

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2336619/2021 - 04º D.P. DIADEMA, 21884996 - 04º D.P. DIADEMA, 2555/21/129 - 04º D.P. DIADEMA, 2336619 - 04º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Samuel Silva Magalhães

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

SAMUEL SILVA MAGALHÃES, qualificado a fls. 10/13, está sendo processado pela prática do crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 07h30, na Rua Imbaúva, altura do n.º 350, bairro Inamar, nesta cidade e comarca de Diadema, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 40 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 30,17 gramas, 62 invólucros plásticos contendo cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 8,45 gramas e 93 invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 285,03 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 04/05 e laudo de constatação a fls. 21/23.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 47/49) o réu foi notificado e citado (fls. 90/91 e 142), estando a defesa inicial apresentada às fls. 100/102 pelo Defensor Público nomeado. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 06/04/2022 (fl. 103).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas comuns e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo diante da quantidade e nocividade da droga cocaína e crack, além dos maus antecedentes, acolhendo a atenuante da confissão, discordando da redução da pena ante a reiteração criminosa, discordando ainda da substituição da pena corporal pela pena restritiva de direitos, fixando-se regime prisional mais gravoso, sem direito de apelo em liberdade. Por fim pleiteia a perda do numerário apreendido.

Já o d. Defensor Público reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão, com o redutor da pena e sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 04/05, nos autos de constatação e no definitivo (respectivamente às fls. 21/23 e 128/130), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais militares (fls. 2/3), estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas e, avistaram um indivíduo, identificado como Samuel Silva Magalhães, com um saco branco nas mãos. Ao avistar a viatura o indivíduo Samuel correu, mas conseguiram alcançá-lo. Realizaram a abordagem, constataram que no interior da sacola branca que o indivíduo Samuel carregava, continha 62 porções/invólucros de substância amarelada semelhante a cocaína na forma de crack; 40 porções de substância branca semelhante a cocaína e 93 porções de substância esverdeada semelhante a maconha. Ainda, a quantia de R\$ 25,00 em dinheiro. O indivíduo confessou que vendia entorpecente no local.

Sob o crivo do contraditório o policial Amaro Serafim reiterou que estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas e ali avistaram o réu, que fugiu a pé. Houve um acompanhamento a pé, sem perde-lo de vista, e o alcançou. Com ele estavam as drogas e o dinheiro das vendas delas. Já o tinha visto outra vez, num roubo, uns dois anos atrás. Foi a primeira vez que o viu naquela biqueira, e o reconhece. Foi apreendida cocaína, crack e maconha, além do dinheiro.

Neste sentido foi o depoimento judicial do policial Flavio Moreira alegou que estavam em patrulhamento pela região onde já sabiam que eram vendidos entorpecentes

e por isso era prioridade de patrulhamento or ter uma creche e uma UBS nas proximidades. Passaram com a viatura e observou o réu. Nesse momento o acusado demonstrou atitude estranha e correu. Seu parceiro desembarcou e correu atrás dele, e foi também logo após estacionar a viatura. Não os perdeu de vista. Viu o réu dispensar a sacola ao solo e dali uns quinze metros o réu foi detido por seu parceiro. Dentro da sacola encontraram os entorpecentes (maconha, crack e cocaína) e o réu confessou a venda alegando ter dívidas a serem pagas. O dinheiro estava com ele e confirmou que era da venda das drogas.

O réu, em solo policial (fl.11) respondeu que está vendendo drogas há poucas semanas e recebe por dia dez por cento do valor da venda dos entorpecentes, algo em torno de R\$ 400,00 a R\$ 500,00.

Em juízo o acusado alegou que tinha saído de uma clinica de recuperação e saiu para morar com sua irmã. O aluguel atrasou, tem quatro filhas para criar, e por fraqueza acabou tendo uma recaída até pelo falecimento de seus pais, e acabou aceitando ir traficar. Tem duas passagens por tráfico quando menor de idade e uma por roubo. Não sabia mais vender as drogas e um rapaz lhe explicou, e por volta das 8:00 hs, os policiais chegaram e ele mais dois rapazes correram e foi abordado e os policiais acharam a sacola com as drogas. Foi uma burrice que lhe complicou, por ter agido de cabeça quente, e está arrependido.

Logo, o interrogatório com a confissão do acusado, que não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária.

Ademais, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Não procede a tese de se tratar de mero usuário como o réu tentou fazer crer nessa audiência ao alegar já ter sido internado para tratamento do vício, posto que não comprovou tal fato, o que tão pouco lhe favoreceria dado que geralmente usuário acaba por traficar, até para o sustento de seu vício, condutas que não se anulam. A condição de usuário de drogas não afasta a traficância, uma vez que é comumente sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem. Nesse sentido temos: A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira).

Afasto, ainda, alegação de estado de necessidade também trazida hoje pelo réu ao alegar estar sem trabalho, com aluguel a pagar e quatro filhas para sustentar, o que também não foi por ele provado como lhe competia esse ônus. Não bastasse isso, não há de se acolher a situação de desemprego e dificuldade econômica do réu como excludente de ilicitude ou culpabilidade, porque os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da

sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. 'Também não há que se falar em estado de necessidade, pois não há provas nos autos de que o apelante passava por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar a lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos' (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011). O réu, como boa parte da população brasileira está passando por dificuldade financeira e nem por isso as pessoas de bem optam por praticar crime ao seu sustento.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaina), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl. 64), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito, e especialmente a grande quantidade do narcótico apreendido (195 no total), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, a aumentar a pena base, que ora fixo, em primeira fase, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes e sim a atenuante da confissão, e tendo sido utilizado o interrogatório como meio de prova de autoria para a fundamentação do presente decreto condenatório, milita em seu favor a atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, a reduzir a pena ao mínimo legal (05 anos de reclusão mais 500 dias-multa).

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, embora seja primário o acusado (fls.33/35), tem-se condenação em solo recursal por crime de roubo (fl. 33) e várias medidas sócio educativas aplicadas contra si, também por tráfico (fl. 35 e 76), somado à apreensão quantia em dinheiro (fl. 64) proveniente de efetivas vendas de drogas feitas a usuários, disseminando e contribuindo com o vício e, portanto, sua maior dedicação à mercancia ilícita, entendo que o redutor de ½ é o razoável e proporcional à maior dedicação do réu à traficância ilícita, totalizando assim 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Contudo, incabível a benesse do art. 44 do CP, não se mostrando suficiente nem eficaz à reprovação da conduta do agente, menos ainda socialmente recomendável sob pena de potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade a conduta, dado que viola mais intensamente o bem jurídico tutelado, somado ao elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem do tráfico seu meio de vida.

Não bastasse isso: O artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de

diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves .

A teor do disposto nos artigos 33, do Código Penal, fixo o regime prisional semiaberto, considerando a quantidade da pena, mas também a preponderância da natureza e da quantidade da droga, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Veja: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional.” (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019). E na presente hipótese tem-se a grande quantidade de narcóticos, a maioria deles de natureza prejudicial à saúde, de alto poder de viciar.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas (fls. 33, 35 e 76), bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado. Ora: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de seis meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP,

rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra SAMUEL SILVA MAGALHÃES, qualificado a fls. 10/13, pela prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e o faço para condená-lo à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está.

Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensão a exigibilidade de pagamento de custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (R\$ 25,00 - fl. 64/65), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA